

1500203-77.2021.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... mínimo, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto, bem como a substituição por pena restritiva de direito (fls. 210/219).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

Segundo a inicial acusatória, "o denunciado possui sólido envolvimento no tráfico de drogas e, na data em questão, foi preso em flagrante pela Polícia Militar enquanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500203-77.2021.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500203-77.2021.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2205874/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 19341569 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2086/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2205874 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2205874 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2086/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DINIZ FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

THIAGO DINIZ FERREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 16, §1º, IV, da lei 10.826/03, sob a acusação de que, na data de 31 de julho de 2021, por volta das 20h40min, na Avenida Três Marias, altura do número 350, Bairro Três Marias, nesta cidade e Comarca, bem como no local denominado por "Antigo Piso

Avaré", também nesta cidade e Comarca, trouxe consigo 4 (quatro) porções de maconha, sendo três delas em forma de tijolo e embaladas por fita adesivas e a outra sem embalagem específica, com peso bruto de 2.832,56g (dois mil, oitocentos e trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas) e teve em depósito e guardou 7 (sete) porções de maconha, em forma de tijolo e embaladas por fita adesiva, com peso bruto de 6.857,86 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete gramas e oitenta e seis centigramas), para entrega e consumo de terceiros, substância esta causadora de dependência física e psicológica, apreendidas a fls. 19/20, constatadas como tal pelo laudo pericial preliminar a fls. 24/26 e confirmadas pelo exame químico toxicológico a fls. 94/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, na mesma data, por volta das 20h40min, no local denominado por "Antigo Piso Avaré" e na residência de sua genitora, ambos nesta cidade e Comarca, portou e possuiu 1 (uma) arma de fogo de repetição, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, e 15 (quinze) cartuchos, calibre .38, sendo sete da marca CBC, cinco da marca Aguila e três da marca Federal, sem autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante e demais peças do Inquérito Policial às fls. 01/111. Em audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 68/70). Mandado de prisão cumprido a fls. 91/92. Devidamente notificado (fls. 134), o réu apresentou Defesa Prévia (fls. 141). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021, oportunidade na qual foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 143/146). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu interrogado (fls. 196/197 e gravações audiovisuais).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e, ao final, pugnou pela procedência da ação a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 201/206). A douta defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto, bem como a substituição por pena restritiva de direito (fls. 210/219).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

Segundo a inicial acusatória, "o denunciado possui sólido envolvimento no tráfico de drogas e, na data em questão, foi preso em flagrante pela Polícia Militar enquanto promovia o citado comércio ilícito, oportunidade em que fazia uso de uma arma de fogo com numeração suprimida. Ocorre que, durante patrulhamento de rotina, uma equipe da Polícia Militar encontrou o acusado em via pública. Ele trazia consigo uma mochila e, ao notar a presença dos policiais, apresentou comportamento incomum, de nervosismo, e empreendeu fuga correndo. Os policiais, então, acompanharam THIAGO, que entrou em um terreno e pulou o muro de uma residência, saindo na Avenida Três Marias, quando foi finalmente abordado para revista pessoal. Com ele os policiais lograram êxito em encontrar no interior da mochila três porções de maconha em forma de tijolo e uma porção menor da mesma droga, além de uma balança de precisão. THIAGO revelou aos policiais que trabalhava como vigia no antigo Piso Avaré e, dando continuidade às diligências, os policiais rumaram até o local encontraram outros sete tijolos de maconha enterrados. Ainda, os policiais encontraram escondidas em uma meia nove munições de arma de fogo. O acusado contou que mantinha um revólver na residência de sua genitora, indicando o endereço, sendo a arma de fogo e o restante da munição apreendidas pelos policiais. A arma de fogo e as munições foram periciadas e constatou-se sua aptidão para disparo e pleno funcionamento, conforme laudo de balística forense a fls. 102/109. É certo que a apreensão da droga, sua forma de embalagem, a apreensão da balança de precisão, as declarações dos policiais militares e, sobretudo, as circunstâncias fáticas da prisão, evidenciam que o acusado se dedica ao tráfico ilícito de drogas".

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo auto de constatação provisória da substância (fls. 24/26), fotografias

a fls. 27/30, pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 94/98, laudo de balística forense a fls. 102/109, bem como por toda prova oral produzida.

A autoria também é certa e indubitavelmente recai sobre o réu.

A testemunha de acusação Marlon Diniz Araujo, policial militar, em juízo, contou "que em patrulhamento de rotina avistaram o acusado o qual, ao perceber a viatura, empreendeu fuga. Porém, conseguiram alcançá-lo e, na abordagem, localizaram dentro da mochila 03 tijolos de maconha e uma balança de precisão. Contou que rumaram até o local em que o réu se encontrava antes de empreender fuga e lá localizaram mais 07 tijolos de maconha e 09 projéteis calibre 38 no interior de uma meia. Em diligência até a residência do acusado encontraram um revólver do mesmo calibre com numeração suprimida".

A testemunha Diego Pires do Prado, também policial militar, judicialmente, reprisou a assertiva de seu colega.

O réu Thiago, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Relatou "que dentro da mochila somente possuía seus itens para alimentação e tinha uma porção pequena no bolso para seu consumo".

Pois bem, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observo que a negativa do réu não encontra amparo nas demais provas do feito, sendo de rigor a condenação.

In casu, a tipificação do crime de tráfico de drogas extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (10 tijolos de maconha pesando mais de 9 kg), do modo pelo qual estava acondicionada, bem como da balança de precisão.

Neste passo, ressalto que a finalidade mercantil com que o réu trazia e guardava as substâncias entorpecentes restou evidente, pois, a quantidade de drogas apreendidas, por si só, já é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo, pois, incompatível com o uso momentâneo.

Nesse contexto, a versão do réu, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação.

Assim, a mendaz versão do réu restou ilhada nos autos e foi infirmada pelos relatos dos policiais, que foram absolutamente coerentes e bastaram à comprovação dos fatos, por não haver na hipótese qualquer contradição ou indicio de que tenham faltado com a verdade para incriminar falsamente o réu.

Ora, a negativa de autoria do réu nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade.

Ademais, os policiais militares, responsáveis pela prisão, confirmaram os termos da inicial acusatória e evidenciaram a responsabilidade criminal do réu. Por isso, força convir que seus depoimentos merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os seus depoimentos prestados extrajudicialmente.

Destarte, os elementos probatórios coligidos estão a revelar iniludível traficância. Não se vislumbra qualquer interesse dos guardas em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202), prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho que, como visto, não tinham razão para incriminá-lo, graciosamente, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, art. 214). Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar seus depoimentos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou em faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido:

"A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são

válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifo nosso)"

Desta feita, examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o réu escondia as substâncias entorpecentes e a balança de precisão, conforme os depoimentos coerentes e insuspeitos dos agentes públicos, que descreveram verossimilmente a apreensão das drogas. Igualmente indisfarçável é a finalidade comercial da droga, mesmo não tendo sido flagrado em atitude de mercancia de entorpecente.

De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, inicialmente, observo que é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico para sua configuração. Neste sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci, ao classificar o tipo previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003: "Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal, em especial por se tratar de objeto de uso proibido ou restrito); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido) nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas possuir, portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar; unissubsistente (cometido num único ato) ou plurissubsistente (cometido em vários atos), conforme o meio eleito pelo agente. Admite tentativa na forma plurissubsistente." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 94/95).

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E RISCO CONCRETO DE DANO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. Para sua configuração, basta o dolo genérico, ou seja, é suficiente a posse de arma de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a existência ou não de dolo específico, bem como a ausência de risco concreto de dano. Bem delineada, nas

instâncias ordinárias, a conduta do paciente, não há falar em absolvição ou desclassificação na via estreita do habeas corpus, ante o necessário revolvimento fático-probatório inadmissível na via eleita. Habeas corpus não conhecido" (Habeas Corpus nº 305.405-RS, Relator Ministro Ericson Marinho, Desembargador convocado do TJ/SP, 6ª Turma, j. em 18/11/2014, DJe de 26/02/2015) (destaquei)

...
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. (...) TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...) 2. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância, não havendo falar em ausência de lesividade, aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, nos quais o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1252964/PR, Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. em 12/11/2013, DJe de 28/11/2013) (destaquei)

Pois bem, note-se que as testemunhas de acusação descreveram a conduta criminosa do réu tanto em solo policial quanto em juízo, com riqueza de detalhes. Sublinhe-se que, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa, os policiais prestam o compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho (artigo 202 do CPP), além do que, na qualidade de agente público, possuem fé pública, gozando de presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que por sinal não foi afastada pela louvável defesa.

Além do mais, não há nos autos qualquer prova de que as testemunhas fossem urdir sórdida e falsa incriminação ao réu, a título de prejudicá-lo, gratuitamente, mentindo sobre o réu possuir arma de fogo e munições de maneira ilícita, nada havendo nos autos que pudesse desmerecer as palavras das testemunhas. O certo é que toda a prova oral traz versão coerente dos fatos, dando conta de um robusto conjunto probatório suficiente para ensejar um decreto condenatório.

Ressalte ainda que, in casu, o laudo de balística a fls. 102/109, certificou que as munições e armas apreendidas possuíam potencialidade lesiva e que o número de série da arma estava obliterada, havendo, portanto, o perfeito enquadramento no tipo incriminador previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, do diploma legal. Frise-se ainda, que esta figura típica tem por objetivo abranger qualquer armamento cujos sinais identificadores possam ter sido eliminados, pouco importando se o calibre é permitido ou proibido.

Neste aspecto, ad argumentandum, saliente-se que a alteração trazida pela Lei nº 13.964/19, embora tenha revogado parágrafo único e inserido o §1º, em nada altera seu conteúdo, haja vista que os incisos que descrevem a conduta típica, bem como a pena em abstrato se mantiveram os mesmos, razão pela qual, não há que se falar na aplicação retroativa da lei.

Desta feita, o crime em exame é de perigo e a conduta imputada ao acusado é de ordinário ato de preparação de diversos delitos. A sociedade tem reconhecido a disponibilidade descontrolada de armas de fogo como fator de fomento da violência, que tem sido causa marcante de comprometimento da qualidade de vida, em especial em grandes cidades, aí porque a legislação atual não apenas criminaliza o porte de arma e as condutas afins, mas o faz de modo severo, com claro intuito de interceptar, ainda na preparação, condutas tendentes ao cometimento dos crimes de dano propriamente ditos.

Assim identificado o espírito da norma em comento e tendo-se em conta seu fim social, é indubitável que a conduta do réu se reveste de tipicidade, não limitada a intervenção estatal a obstar lesão à vida e à integridade física, mas a qualquer bem jurídico tutelado e passível de ser ofendido mediante utilização de arma de fogo. Confirmou-se que o revólver tinha a numeração suprimida, deliberadamente comprometida, de tal modo que impossibilitada sua identificação e apuração de sua origem, justificando-se a aplicação de punição mais severa, o que motiva o enquadramento da conduta de porte não no artigo 12 ou artigo 14, mas no artigo 16 da Lei 10.826/03, por força do disposto no inciso IV do parágrafo primeiro. Por fim, o artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 pune o porte de

arma com numeração suprimida, mesmo que a supressão não tenha sido feita de mão própria pelo agente, bastando a conduta de portar a arma não identificada para caracterizar o crime. Trata-se de delito considerado mais grave por dificultar o controle estatal de circulação de armas de fogo.

Por derradeiro, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação e/ou perseguição. Não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu THIAGO DINIZ FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da lei 10.826/03. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Em relação ao tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais (F.A. e certidões a fls. 166/183) e, tendo já cumprido pena privativa de liberdade, voltou a delinquir. Isso mostra que tem conduta social reprovável e personalidade voltada à delinquência, já que a mais grave das penas ordinariamente previstas em nossa legislação penal não o intimidou a praticar novo delito. Sobressai-se, no caso em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da lei 11.343/06. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, é o caso de se reconhecer a agravante da reincidência (fls. 166/171). Assim, aumento em mais 1/6 (um sexto) a pena, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não estão presentes outras agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, entendo que não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos, precipuamente, a reincidência. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e a natureza da substância apreendida levaram à conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas, ou seja, não se trata de traficante ocasional" (HC 297447/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/11/2014). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pela reincidência e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: "A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Desta forma, fixo em definitivo a pena a cumprir de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

No tocante ao crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na primeira fase de dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais (F.A. e certidões a fls. 166/183) e, tendo já cumprido pena privativa de liberdade, voltou a delinquir. Isso mostra que tem conduta social reprovável e personalidade voltada à delinquência, já que a mais grave das penas ordinariamente previstas em nossa legislação penal não o intimidou a praticar novo delito. Desta feita, elevo a

pena base em 1/6 (um sexto) atingindo o patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, em razão da reincidência (fls. 166/171), elevo e mais 1/6 (um sexto) a pena, atingindo 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa. Por fim, na terceira fase, entendo que não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal. Em face do cúmulo material de crimes, fixo em definitivo a pena a cumprir em 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

A pena imposta ao réu deverá ter seu início de cumprimento em regime FECHADO. Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não concluiu, por outro lado, pela imposição indiscriminada de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena em tais delitos. Ao contrário. Ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/12/2013). O caso dos autos, no qual se constatou a prática de tráfico de considerável quantidade de entorpecente, demanda a adoção de regime prisional mais severo, sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que demonstram desprezo à manutenção da ordem pública.

É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de

direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Avaré.

Deixo de reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Ademais, o réu foi preso preventivamente e permaneceu recolhido por todo o processo e não seria razoável, agora que foi condenado, ser colocado em liberdade, ainda que diante do regime imposto pela lei e do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, que deve ser exemplarmente punida. Recomende-se.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo, exceto a carteira apreendida contendo os documentos pessoais do réu, os quais determino a restituição após o trânsito em julgado. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova.

Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome do réu/condenado recorrente, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) do condenado; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando sua condenação, com a devida identificação dele, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei. P.I.C.

Avare, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA